

1500856-59.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... que o local é conhecido como ponto de tráfico e viram o réu sozinho com uma sacola nas mãos. Disse que o abordaram e na sacola localizaram drogas (cocaína, "crack" e maconha, divididas em porções) e em poder dele havia dinheiro trocado (R\$8,00). O réu confessou o tráfico. Na delegacia, o réu falou que ia receber R\$50,00 para segurar e levar as drogas para um ponto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500856-59.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500856-59.2022.8.26.0537 Controle nº 682/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILO RICARDO DE MELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

NILO RICARDO DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 28 de abril de 2022, por volta das 07:00 horas, na Rua Raul Seixas, altura do n.º 108, Bairro Jardim Casa Grande, adquiriu, recebeu, trazia consigo e transportava, para fins de entrega e consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 58/61).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 90/93), sendo recebida a denúncia em 27.07.22 (fls. 102/103). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pelos antecedentes e pela reincidência, afastada a redução do art. 33, §4.º, fixação de regime fechado,

vedação do direito de recorrer em liberdade e perda do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, compensação da reincidência com as confissões, a aplicação do art. 387, § 2.º, do CPP e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 05), o réu confessou que estava transportando os entorpecentes apreendidos até o ponto de venda. Disse que estava na comunidade, próximo a um local conhecido como "Bananeira", quando foi abordado por um homem desconhecido, que sabendo que era usuário de "crack", ofereceu R\$ 50,00 e duas pedras de "crack" para que levasse uma sacola com drogas até um ponto de tráfico. Falou que aceitou levar a sacola com drogas até o local combinado, mas durante o trajeto, após ter passado em um bar para comprar cigarros e um corote, foi abordado pelos policiais, que visualizaram a sacola e encontraram as drogas que transportava. Alegou que "não estava traficando, apenas aceitou levar as drogas até o ponto de tráfico" (sic).

Em juízo, narrou que tinha R\$8,00, é usuário compulsivo obsessivo de "crack" e estava esperando arrumar mais R\$2,00 reais para comprar. O vendedor pediu para levar a sacola até um ferro velho, que lhe daria R\$50,00 e duas "pedras" para usar e aceitou transportar as drogas. Passou num bar, comprou cigarros, corote, pôs na sacola e depois quando saiu foi abordado pelos policiais. Trabalhava por contrato (empurrava os carrinhos no Extra), até dezembro. Posteriormente, não arrumou mais emprego e teve recaída na bebida e drogas. Tem duas condenações por furto, depois que cumpriu as penas foi para uma casa de recuperação e quando saiu arrumou esse serviço terceirizado do Extra. Pede uma oportunidade para recomeçar sua vida longe das drogas. Está encarcerado, mas livre das drogas.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/04), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico, estavam em operação com viatura descaracterizada quando se depararam com o réu (trajava bermuda bege, camiseta e chinelos) em atitude suspeita, segurando uma sacola plástica nas mãos e resolveram abordá-lo. Relataram que o réu confessou que estava traficando drogas e ao verificarem a sacola plástica que ele carregava localizaram um estojo, contendo 20 porções de maconha, 10 invólucros de cocaína, 29 pedras de "crack" e R\$ 8,00, em cédulas trocadas. Afirmaram que o réu informou que vendia as porções de "crack" e maconha por R\$ 5,00 e a de cocaína por R\$ 10,00.

Cléber (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico e viram o réu sozinho com uma sacola nas mãos. Disse que o abordaram e na sacola localizaram drogas (cocaína, "crack" e maconha, divididas em porções) e em poder dele havia dinheiro trocado (R\$8,00). O réu confessou o tráfico. Na delegacia, o réu falou que ia receber R\$50,00 para segurar e levar as drogas para um ponto de tráfico. Porém, réu não estava com os R\$50,00. Existem bares, mas o réu estava há uma distância de uns 100 metros destes. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Marcus.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 10/11 - 29 pedras de "crack", 10 invólucros de cocaína e 20 porções de maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, as confissões informal, extrajudicial e judicial e

os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

“Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

“Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio” (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, receber, trazer consigo e transportar. Tanto as condutas de trazer consigo, quanto transportar são típicas, pelo que o réu confessou nas duas fases.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art.

28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (29 pedras de “crack”, 10 invólucros de cocaína e 20 porções de maconha), demonstram que se destinava ao tráfico. Ademais, o réu sequer provou que é usuário ou que ficou internado.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 15/17) e laudo definitivo (fls. 116/118).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos, possui antecedentes (fls. 42 – proc. 47-27.2014 – pena julgada extinta por indulto em 06.07.16; fls. 44 – proc. 23161-50.2010) e é reincidente (fls. 43/44 – proc. 1236-98.2018 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 04.05.21).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Não é caso de aumento da pena-base pela quantidade e variedade de drogas, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta Comarca inferior a 100).

Compenso a reincidência e a confissões extrajudicial e judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

“A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: “ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal” (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE

POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois possui antecedentes (fls. 42 – proc. 47-27.2014 – pena julgada extinta por indulto em 06.07.16; fls. 44 – proc. 23161-50.2010) e é reincidente por furto (fls. 43/44 – proc. 1236-98.2018 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 04.05.21), o que denota personalidade voltada para crimes, que são seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita.

Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto.

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante dos antecedentes por tráfico e reincidência (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO NILO RICARDO DE MELO à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, bem como o requerimento do M.P de não recorrer em liberdade e por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a

prisão em flagrante em preventiva, recomende-se na prisão em que se encontra. Sem custas (Lei n.º 11.608/03 por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 10 e 123) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União (art. 63 da Lei n.º 11343/06), providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto ao estojo e à sacola plástica apreendidos (fls. 10), já periciados (fls. 119/120 e 121/22), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminadas. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 64), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 11 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA